

1500045-60.2022.8.26.0550

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... a desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e foram apresentadas teses relativas à fixação da pena (SAJ).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500045-60.2022.8.26.0550 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500045-60.2022.8.26.0550

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2013277/2022 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 22457802 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 9/22/616 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2013277 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Iago Gabriel Mazzeo de Macedo e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

IAGO GABRIEL MAZZEO DE MACEDO e ELIEDISON AMADOR BARBOSA, qualificados nos autos,

estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso VI, e no artigo 35, c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque em 14 de janeiro de 2022, às 14h00, na Avenida 10 JG, 459, Jd. Guanabara, nesta cidade e comarca de Rio Claro, os acusados, agindo em concurso, entre si e com o adolescente Abner Albino Cardoso, teriam vendido, guardado e trazido consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 19g de maconha, distribuídas em 5 embalagens, 2g de crack, distribuídas em 16 pedras e 0,7g de cocaína, em um microtubo, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, IAGO GABRIEL MAZZEO DE MACEDO e ELIEDISON AMADOR BARBOSA e o adolescente Abner Albino Cardoso, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 18/21), auto de exibição e apreensão (fls. 22/24), relatório de investigação (fls. 34/39), laudo de constatação (fls. 42/45) e exame químico-toxicológico (fls. 125/128).

Os acusados foram notificados (fls. 160 e 162) e apresentaram defesa prévia (fls. 166/168 e 169/173). A denúncia foi recebida (fls. 186/189).

Superada a instrução e a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação dos réus nos termos da denúncia. Para ambos os acusados pugnou pela não aplicação do privilégio legal e regime fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade (SAJ).

A Defesa constituída do corréu Iago requereu a absolvição diante da fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, foram apresentadas teses relativas à fixação da pena (SAJ).

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu a absolvição do corréu Eliedison, diante da fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, foi requerida a desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e foram apresentadas teses relativas à fixação da pena (SAJ).

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 18/21), auto de exibição e apreensão (fls. 22/24), relatório de investigação (fls. 34/39), laudo de constatação (fls. 42/45) e exame químico-toxicológico (fls. 125/128).

A autoria do delito de tráfico foi demonstrada a contento.

Ouvido perante a autoridade policial, o réu Iago Gabriel Mazzeo de Macedo negou os fatos. Declarou que não está envolvido com o tráfico de entorpecentes e que conhece o adolescente Abner e o Imputável Eliedison apenas de vista, não sendo amigo de nenhum desses. Na data dos fatos estava defronte a sua residência para fumar um cigarro e pediu um isqueiro "Bic" emprestado para Abner, retornando para a sua residência logo em seguida. Posteriormente, policiais civis se apresentaram em sua residência exibindo um Mandado de busca domiciliar e passaram a realizar busca pela sua residência. Foi encontrado uma porção de maconha já pronta para o uso, a qual seria usada para consumo pessoal. Afirmou que os valores encontrados no local

possuem procedência lícita. (fls. 07).

Em juízo, o corréu Iago negou que praticava o tráfico de drogas. Esclareceu que não conhece Eliedison, mas somente o adolescente Abner, pois o vê todos os dias na rua andando de bicicleta. Disse que trabalha na garagem de sua casa com seu padasto, fazendo raquetes. Ganha a quantia de um real por raquete. No dia da prisão, tinha terminado de fazer raquete e estava ajudando sua irmã a organizar as coisas para abrir o espetinho que também é na sua residência. Saiu para fumar um cigarro e viu os meninos na rua. Pediu para Abner emprestar um isqueiro "bic" e não foi ele que entregou o isqueiro. Acendeu o cigarro, fumou e entrou. Os policiais bateram no seu portão e disseram que iriam averiguar sua casa. Eles perguntaram se tinha algo de ilícito e respondeu que não, mas que apenas possuía uma quantidade mínima de maconha, já dichavada, para seu consumo. Foram encontrados saquinhos de juju em sua casa, mas que era usado para colocar molhos para o espetinho, quando os clientes levavam para viagem. Foi encontrada a quantia de R\$ 460,00 em sua casa, que estava no rack, junto com umas contas que iriam ser pagas. Não tem acesso ao quarto de sua mãe, então não sabe se tinha dinheiro lá. Negou ter tido contato com Eliedison ou Abner naquele dia. Negou que deixavam dinheiro na caixa de correio em sua residência. As anotações encontradas era de sua irmã e referiam-se às anotações dos gastos que ela possuía. Fazia de 35 a 50 raquetes por dia, pois trabalhava das oito horas ao meio dia. Parte do dinheiro encontrado lhe pertencia e a outra parte pertencia à sua irmã, pois trabalhava com ela no espetinho e o dinheiro localizado era proveniente da venda realizada. O isqueiro "bic" foi fornecido por um dos meninos que estava junto de Eliedison e de Abner. Negou ter visto Abner vendendo drogas. Só viu Eliedison no dia da prisão (SAJ).

Ouvido perante a autoridade policial, o réu Eliedison Amador Barbosa negou os fatos. Declarou que na data dos fatos estava no local para fumar um cigarro de maconha, o qual trouxe de sua residência, e que a porção de maconha encontrada também era para o seu próprio consumo. Negou conhecer o adolescente Abner e a pessoa de pronome Iago, bem como ter realizado vendas de entorpecentes e repassado o dinheiro da venda para esse. (fls. 08).

Em juízo, o corréu Eliedison negou que praticava o tráfico de drogas. Acredita que está sendo acusado porque estava no local, mas afirmou que estava lá apenas fumando. Não viu onde os policiais encontraram as drogas. Não conhecia Iago, mas apenas o menor Abner. Conhecia Abner da rua, por fumarem juntos. Não sabe se Abner praticava o tráfico de drogas. No momento da apreensão tinha meia porção de maconha e um cigarro de maconha aceso. Não sabe se o adolescente tinha drogas com ele. Entrou na garagem da casa de Iago, junto dos policiais, mas não entrou no interior da residência. Negou ter deixado dinheiro na caixa de correio da casa de Iago. Estava com uma blusa preta, com listras preta e branca e uma bermuda verde. Não estava de bicicleta. Abner estava de bicicleta e usava uma roupa cinza escura, bermuda e chinelo. Estava no local fazia 15 minutos. Não viu Iago se aproximar. Estava a cerca de três casas de Iago quando foi abordado. Não tinha outras pessoas na rua. Não trabalha e não estuda. Sua mãe lhe dá dinheiro esporadicamente. Tem tatuagens de palhaço pelo corpo e não sabe o significado delas (SAJ).

A testemunha comum Gustavo Felipe Baptista Juliano, policial civil, declarou que receberam a informação de que o indivíduo de nome Iago seria um dos gerentes e distribuidores de entorpecentes de um ponto de tráfico no Jardim Brasília. Em posse dessa informação, diligenciaram ao local e após breve campana constataram que os indivíduos faziam a mercancia de entorpecentes, dentre eles alguns adolescentes, quase na frente da residência de Iago. Depois das vendas, o dinheiro era colocado na caixa de correios da casa de Iago. Na ocasião, foi possível ver a mãe de Iago pegando dinheiro. Em razão desses fatos solicitaram mandado de busca na residência. Na data de cumprimento do mandado de busca, foi realizada nova campana, onde foi possível ver alguns indivíduos na frente da residência vendendo entorpecentes e se deslocando a um local que fica próximo ao muro da escola, pegando entorpecentes e

guardando o dinheiro. Em determinado momento chegou um rapaz de bicicleta, pegou o dinheiro dos menores que faziam a venda e Iago saiu do portão. Esse dinheiro foi entregue ao Iago. Decidiram abordar os indivíduos, que foram identificados como sendo o Eliedison e o menor Abner. Abner já havia sido conduzido em outra oportunidade até a Delegacia por tráfico de drogas no mesmo local. Na residência de Iago, no cumprimento do mandado, encontraram uma folha de papel que aparentemente seria a contabilidade do tráfico, certa quantia em dinheiro em cima do rack e no quarto da mãe dele. Porções de maconha foram encontradas no quarto de Iago. No momento, Iago estava com celular e solicitaram que ele desbloqueasse o aparelho. No celular havia tratativas de entorpecentes de Iago com um indivíduo de nome Theo, que posteriormente foi identificado, sendo cumprido mandado de busca na residência dele também. Todos foram conduzidos para a Delegacia. As campanhas foram realizadas em dois dias diferentes e pode afirmar com certeza que Eliedison e Abner estavam envolvidos no segundo dia. Com Eliedison foi encontrada uma porção de maconha. Observaram, durante a campanha, que Abner e Eliedison se deslocavam para o mesmo ponto para buscar entorpecentes e entregar aos usuários. Com Abner foram encontradas drogas e dinheiro e com Eliedison somente uma porção de maconha. As imagens juntadas nos autos são referentes ao dia da busca. No dia da busca e apreensão acredita que não tinha dinheiro na caixinha de correios que fica na frente da residência de Iago (SAJ).

De igual forma discorreu sobre os fatos a testemunha comum Jorge Luiz Bizarro Teixeira, policial civil, que acrescentou que o local já é conhecido como ponto de venda de drogas e que no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão viram Iago saindo na rua e recebendo dinheiro que acredita ser de Theo, que havia acabado de pegar com um menor. Tudo foi registrado por câmeras fotográficas. Abordaram Eliedison junto com o menor. Iago percebeu a movimentação e saiu no portão. Foram encontradas na sala da residência de Iago, em três lugares diferentes, bastante dinheiro trocado e um manuscrito, que acredita ser do fechamento do tráfico de drogas. Iago tentou justificar que o dinheiro referia-se às contas que seriam pagas, mas não foram encontradas essas contas, e que tinha uma porção de maconha em seu quarto destinada ao seu uso. A maconha já estava dichavada. No quarto da mãe de Iago foi encontrado mais dinheiro em notas trocadas. Só participou da campanha realizada no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Visualizou Eliedison e Abner na traficância. O local é um ponto bem movimentado. Naquele dia Iago não teve contato com o local onde foi encontrado o entorpecente. Receberam informações anteriores de que a droga que chegava no local estaria armazenada na casa de Iago. Nem todas as vendas foram fotografadas (SAJ).

A testemunha de defesa Daniela declarou que conhece Iago do bairro há uns 15 anos. Frequenta a casa dele todos os dias, pois a mãe dele cuida de sua filha. Nunca viu movimento atípico na casa relacionado ao tráfico de drogas. Há um comércio na residência, que é da irmã de Iago, um carrinho de espetinho e refrigerante que funciona todos os dias. Faz aproximadamente quatro anos que deixa sua filha com a mãe de Iago. Tem contato com Iago, pois todas as vezes que vai buscar a filha encontra ele na residência. Iago estava trabalhando com o padraço, de colar raquetes de lixa para a empresa Delta. Nunca viu drogas nem dinheiro em espécie espalhadas pela casa (SAJ).

I) Quanto ao delito previsto no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06:

Pois bem. Verifica-se que o conjunto probatório associado aos elementos colhidos na fase inquisitiva confirmam a prática do delito de tráfico de entorpecentes pelos réus.

Os policiais civis ouvidos em juízo foram firmes e seguros em suas declarações.

Anoto que os depoimentos dos agentes da polícia merecem a normal credibilidade dos

testemunhos em geral, eis que inexistem elementos dos quais se possa extrair que tinham a intenção de incriminar indevidamente os réus, não pesando sobre eles nenhuma suspeição.

Ademais, por se tratar de agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam essencialmente à segurança pública, com o fim de manter a ordem e o bem estar social, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, como no caso dos autos.

Nesse sentido já se decidiu:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF, HC 87.662-5/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, d.j. 05/09/06, DJU 16/02/07 - grifamos);

"O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso." (STJ, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016);

"Furto - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais - Validade. Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário." (TJSP, apelação nº 0001005-35.2014.8.26.0077, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel Des. Grassi Neto, d.j. 17/03/2016 - grifamos).

Como se vê, a negativa dos réus não passa de tentativa de desqualificar os relatos dos policiais civis, tentando fazer crer que não praticavam o tráfico de drogas e que os entorpecentes apreendidos em poder de Eliedison e na residência de Iago destinavam-se ao uso.

Sucumbem os réus às demais provas coligidas aos autos, que dão conta do envolvimento deles com o tráfico, pois os relatos dos policiais civis são seguros nesse sentido, tudo estando a revelar que estavam envolvidos com a prática da mercancia ilícita de drogas e não se vislumbra que os policiais tivessem inventado isso apenas para prejudicar inocentes.

Os relatos dos policiais civis foram harmônicos e convergiram no sentido de que receberam a informação de que Iago seria um dos gerentes e distribuidores de entorpecentes de um ponto de tráfico no Jardim Brasília. Em posse dessa informação, diligenciaram ao local e, após breve campana, constataram que os indivíduos faziam a mercancia de entorpecentes, dentre eles alguns adolescentes, quase na frente da residência de Iago. Em razão desses fatos solicitaram mandado de busca na residência de Iago e, na data de cumprimento do mandado, foi realizada nova

campana, sendo possível visualizar alguns indivíduos na frente da residência vendendo entorpecentes.

Os policiais também relataram que, em determinado momento, chegou um rapaz de bicicleta, pegou o dinheiro dos indivíduos que faziam a venda e levou para Iago. Decidiram abordar os indivíduos, que foram identificados como sendo o corréu Eliedison e o adolescente Abner. Com o adolescente Abner foram encontradas drogas e dinheiro e com o corréu Eliedison uma porção de maconha. Na residência de Iago, no cumprimento do mandado, encontraram uma folha de papel que aparentemente seria a contabilidade do tráfico, certa quantia em dinheiro em cima do rack e no quarto da mãe dele, bem como porções de maconha no quarto de Iago.

Assim, a versão apresentada pelos réus - de que não praticavam o tráfico de drogas e de que a pouca quantidade encontrada destinava-se ao consumo próprio - é inverossímil, eis que restou totalmente isolada nos autos.

Além disso, houve registro visual quanto às ações dos réus no dia dos fatos, que foram devidamente retratadas no relatório de investigação de fls. 34/39 e confirmam a efetiva prática do tráfico por eles, nos exatos termos em que informado pelos policiais civis.

Pelas fotografias, foi possível visualizar o corréu Eliedison e o adolescente Abner se encontrando e se reunindo com o corréu Iago, que saiu no portão, recebeu o dinheiro e fez a conferência do valor.

Destarte, restou demonstrado que na data dos fatos os réus praticavam o tráfico de drogas, conforme imagens constantes a fls. 35/38 dos autos.

As justificativas apresentadas por eles em seus interrogatórios não se sustentam. Não houve comprovação nos autos de que estavam no local dos fatos com outra finalidade que não a de praticar o tráfico de drogas.

Quanto ao dinheiro apreendido na residência do corréu Iago, em notas fracionadas, embora ele tenha alegado que era proveniente da venda de espetinhos realizada junto de sua irmã, não foi produzida qualquer prova nesse sentido, de modo que a origem lícita do valor total apreendido não foi devidamente comprovada.

O mesmo ocorreu com os valores encontrados no quarto da genitora de Iago, que não tiveram a origem lícita devidamente comprovada. Em sentido contrário das alegações da Defesa, no relatório investigativo que embasou o pedido de busca e apreensão, há notícias de que a mãe de Iago auxiliava o filho no recebimento de valores provenientes do tráfico.

No mais, foram apreendidas na residência do corréu Iago duas folhas de papel com manuscritos sugestivos de movimentação de tráfico.

Inexiste qualquer prova, indício ou sugestão de que tivessem os policiais alguma motivação lógica para falsamente incriminarem os réus

Desse modo, as circunstâncias das prisões, precedidas de campanhas realizadas no local dos fatos em duas oportunidades (com registros visuais de uma delas, reproduzidos a fls. 35/38), a apreensão ter decorrido do cumprimento de mandado de busca e apreensão nos autos cautelares nº 1500017-92.2022.8.26.0550, o encontro de dinheiro, em notas fracionadas, na residência do corréu Iago, sem a origem lícita devidamente comprovada, bem como de duas folhas de papel com manuscritos sugestivos de movimentação de tráfico, aliadas às declarações harmônicas prestadas pelos policiais civis, demonstram que as drogas apreendidas pertenciam aos réus e se destinavam à mercancia ilícita, restando afastada a pretensão de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

No mais, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, tendo em vista que os depoimentos dos policiais civis convergiram para descrever a efetiva participação do adolescente Abner na prática ilícita. Conforme relatado por eles, o adolescente ocultava os entorpecentes no matagal e quando solicitado ia até o local buscar para fazer a entrega a terceiros. Há nos autos fotografia dele praticando duas vendas, conforme fls. 35, bem como dele buscando os entorpecentes no matagal, conforme fls. 36. De rigor, portanto, a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

Assim, contrariamente ao que foi sustentado pela Defesa, certo é que as provas são robustas para sustentar um decreto condenatório, de forma que a responsabilização dos réus pelo delito previsto no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 é medida de rigor.

II) Quanto ao delito previsto no artigo 35, c.c. o artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06:

É caso de absolvição dos réus em relação à acusação de associação para o fim de praticar o crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, tendo em vista que não foi produzida prova nos autos a indicar o vínculo associativo permanente existente entre eles na prática do tráfico de drogas.

Fato é que os réus e o adolescente Abner exerciam a traficância no dia dos fatos, como acima demonstrado. No entanto, não há provas firmes e seguras de que estavam associados de forma permanente para tanto.

Nos dizeres de Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, na obra Lei de Drogas Anotada, Ed. Saraiva 1ª Edição, p. 120: "É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores. Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação".

Para a configuração do crime de associação para o tráfico, há necessidade do preenchimento dos seguintes requisitos básicos: vínculo associativo permanente para fins criminosos; predisposição para a prática de uma série indeterminada de crimes e contínua vinculação entre os associados.

No presente caso, não houve nenhum trabalho policial ou investigação mais aprofundada indicando a verdadeira associação dos réus e do adolescente para a prática desse crime. O fato de os policiais terem visualizado os réus em um ou duas oportunidades praticando o tráfico de drogas em local conhecido como ponto de drogas não é suficiente para a configuração do crime de associação para os fins de tráfico.

No mais, no relatório investigativo que embasou o pedido de busca e apreensão na residência do corréu Iago sequer foram mencionados os nomes do corréu Eliedson ou do adolescente Abner.

Desse modo, considerando que os requisitos necessários para a configuração do delito de associação para o tráfico não restaram devidamente comprovados pela prova produzida nos autos e pelas investigações realizadas, a absolvição, portanto, é medida de rigor.

III) Da dosimetria da pena:

Acolhida, portanto, a tese acusatória, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena dos réus.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base dos réus no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias hábeis a majorá-la. Assim, a pena inicial será de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa em relação ao corréu Eliedison. No entanto, deixo de minorar a pena, diante da expressa vedação constante na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao corréu Iago, reconheço a agravante da reincidência (fls. 144/145 – processo nº 1500177-25.2019.8.26.0550), de modo que majoro a pena desse réu em 1/6, de forma que passará a 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a causa de aumento decorrente do envolvimento de menor na empreitada, no caso, o adolescente Abner, o qual participava ativamente da ação, se revezando na venda de entorpecentes. Assim, aumento a pena dos réus em 1/6, passando a 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa para o corréu Eliedison e 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa para o corréu Iago.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 quanto ao corréu Iago, tendo em vista que esse réu é reincidente. Assim, torno a pena acima fixada definitiva.

Já quanto ao corréu Eliedison, observo a referida causa de diminuição de pena, tendo em vista que ele é primário, portador de bons antecedentes e não há notícias nos autos de que integra organização criminosa. Destarte, de rigor a redução da pena em seu grau máximo, ou seja, em 2/3, de maneira que passará a 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

O reconhecimento da referida causa de diminuição de pena, denominada “tráfico privilegiado”, traz novas consequências aos réus condenados pela prática dessa modalidade de crime, diante do recente entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

A Súmula 512 do STJ, editada em 11 de junho de 2014, após o julgamento do REsp 1.329.088/RS - de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, dispunha que “A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas”.

Ocorre que, em sessão realizada no dia 23/06/2016, o Plenário do STF, por maioria de votos, no Habeas Corpus nº 118.533-MS, firmou entendimento no sentido de que o denominado tráfico privilegiado de drogas, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, não tem natureza hedionda.

Conforme esposado pela Ministra Relatora do acórdão, Cármen Lúcia, somente as figuras delitivas definidas no artigo 33, “caput” e §1º, da Lei 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, considerando que o delito na modalidade privilegiada apresentaria “contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”.

Embora o referido julgamento proferido pelo Pleno do STF não tenha efeito vinculante nem eficácia erga omnes, a Terceira Seção do STJ acolheu a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo e decidiu revisar o entendimento consolidado no julgamento do REsp nº 1.329.088/RS – Tema 600, cancelando o enunciado da Súmula 512, em observância aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, conforme segue:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA.

ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa." (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS – Tema 600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça." (STJ, Pet 11.796-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, d.j. 23/11/2016)

Nesse sentido, já decidiu o C. TJSP:

"Habeas corpus. Pedido de progressão de regime. Suspensão do feito pelo Juízo das Execuções, com fulcro no art. 1.037, II, do CPC. Superior Tribunal de Justiça que julgou questão de ordem, cancelou a súmula nº 512 e firmou entendimento de que o tráfico privilegiado não mais é classificado como crime hediondo. Liminar confirmada. Ordem parcialmente concedida." (HC 2241449-61.2016.8.26.0000, Des. Rel. Luiz Fernando Vaggione, Bauru, 2ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 19/12/2016)

Destarte, não há mais óbice à fixação de regime prisional diverso do fechado para os condenados pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, tampouco à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou à suspensão da execução desta.

No presente caso, considerando que o corréu Eliedison é primário, portador de bons antecedentes e goza de menoridade relativa, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Quanto ao corréu Iago, em razão da reincidência, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Quanto ao corréu Eliedison, presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, e considerando a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em razão da declaração incidental de inconstitucionalidade desta proibição pela referida Corte de Justiça na apreciação do Habeas Corpus nº 97.256/RS, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a ser revertida para entidade de caráter social.

O corréu Iago não terá direito à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e à suspensão condicional da pena, em razão do montante da pena aplicada, da reincidência e do fato do crime praticado ser

equiparado aos crimes hediondos.

O valor do dia-multa será fixado no mínimo legal, diante da falta de maiores informações a respeito da situação financeira dos réus.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública para:

A) condenar ELIEDISON AMADOR BARBOSA à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06. Substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a ser revertida para entidade de caráter social;

B) condenar IAGO GABRIEL MAZZEO DE MACEDO à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de conceder a suspensão condicional da pena ao réu, nos termos da fundamentação.

C) absolver ELIEDISON AMADOR BARBOSA e IAGO GABRIEL MAZZEO DE MACEDO da acusação de terem praticado o crime previsto no artigo 35, "caput", c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, o que o faço com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

O corréu Eliedison terá o direito de recorrer em liberdade.

O corréu Iago não terá direito de apelar em liberdade, tendo em vista que permaneceu preso durante toda a instrução, sendo que não há motivos hábeis a afastar a custódia cautelar. Ademais, a garantia da ordem pública deve prevalecer frente à gravidade do crime praticado e ao fato de ser reincidente, que revela ainda mais a necessidade da custódia cautelar.

Recomendo que permaneça recolhido no estabelecimento em que se encontra.

Declaro a perda em favor da União do valor total apreendido nos autos, eis que proveniente do tráfico de entorpecentes.

Determino a destruição das drogas apreendidas, caso ainda não tenha sido feito. Autorizo, ainda, a destruição dos objetos apreendidos e não reclamados.

Custas "ex lege".

P.I.

Rio Claro, 10 de maio de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA